

1500237-17.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... imputar qualquer comportamento típico e ilícito de tráfico, para além de qualquer dúvida, até porque o réu afirma que era usuário e, em sua confissão, diz que "tomava conta da casa" tendo em conta dívida de droga. É crível que o réu, por possuir dívidas com o tráfico eis que também usuário, como contraprestação tomasse conta da casa na qual os policiais encontraram drogas e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1500237-17.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500237-17.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO TOTH EVANGELISTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual DIEGO TOTH EVANGELISTA, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, do artigo 35, caput, e do artigo 34, todos da Lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 24 de janeiro de 2022 e em datas anteriores, em horário incerto, na Rua João Francisco Regina, n.º 300, Helena Maria, nesta cidade e comarca de Osasco, DIEGO TOTH EVANGELISTA, vulgo Cabelo, qualificado às fls. 09/10, e indivíduo não identificado associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06).

Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, no dia 24 de janeiro de 2022, por volta das 11h30min, na Rua Aníbal Simões, n.º 54, Jardim Elvira, e na Rua João Francisco Regina, n.º 300, Helena Maria, ambos nesta cidade e comarca de Osasco, DIEGO TOTH EVANGELISTA, vulgo Cabelo, qualificado às fls. 09/10, agindo em associação criminosa voltada para o tráfico de drogas com outro indivíduo não

identificado, tinha em depósito e guardava drogas, para entrega ao consumo de terceiros, consistentes em 03 (três) porções de Cannabis sativa L (maconha) – lacre 0000993, com peso líquido de 9,6 gramas, 57 (cinquenta e sete) porções de cocaína – lacre 0000992, com peso líquido de 15,3 gramas, 272 (duzentas e setenta e duas) porções de Cannabis sativa L (maconha) – lacre 0019805, com peso líquido de 1262,3 gramas, 429 (quatrocentos e vinte e nove) porções de cocaína – lacre 0019804, com peso líquido de 88,8 gramas, e 01 (uma) porção de cocaína – lacre 0000994, com peso líquido de 944,1 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 19/20, fotografias às fls. 28/37, relatório de denúncia anônima às fls. 39/42, laudos de constatação às fls. 43/45 e 46/49 e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente acostado aos autos.

Consta, também, que, no dia 24 de janeiro de 2022, por volta das 11h30min, na Rua João Francisco Regina, n.º 300, Helena Maria, nesta cidade e comarca de Osasco, DIEGO TOTH EVANGELISTA, vulgo Cabelo, qualificado às fls. 09/10, agindo em associação criminosa voltada para o tráfico de drogas com outro indivíduo não identificado, possuía maquinário e objetos destinados à preparação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em uma máquina seladora dos invólucros plásticos utilizados para acondicionar cocaína, dois liquidificadores e uma balança de precisão digital.

Narra a denúncia (fls. 108/112) que, no dia 24 de janeiro de 2022, por volta das 11h30min, na Rua João Francisco Regina, n.º 300, Helena Maria, nesta cidade e comarca de Osasco, DIEGO TOTH EVANGELISTA, vulgo Cabelo, qualificado às fls. 09/10, agindo em associação criminosa voltada para o tráfico de drogas com outro indivíduo não identificado, possuía maquinário e objetos destinados à preparação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em uma máquina seladora dos invólucros plásticos utilizados para acondicionar cocaína, dois liquidificadores e uma balança de precisão digital.

Segundo o apurado, o denunciado e indivíduo não identificado constituíram associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, com organização e divisão de tarefas, uma vez que o primeiro era incumbido da função de embalar e armazenar os entorpecentes em sua residência, ao passo que o comparsa não identificado vinha retirá-los para posterior comercialização, além de pagar ao increpado quantia em dinheiro por tal serviço, sendo certo que as atividades ilícitas ocorriam há oito meses.

No dia 24 de janeiro de 2022, policiais civis receberam denúncia anônima reportando que, na Rua João Francisco Regina, n.º 300, Helena Maria, na cidade de Osasco, havia uma residência utilizada como recepção, beneficiamento e distribuição de drogas pela facção criminosa “PCC”, bem como que o ocupante do imóvel era um indivíduo de vulgo “Cabelo”, que também poderia ser localizado em um lava-rápido situado na Rua Anibal Simões, n.º 54, Jardim Elvira, no município de Osasco.

A denúncia em questão também apontava que o dono dos entorpecentes era um indivíduo de prenome “Eberte”, vulgo “Magrão” ou “Mortão”, integrante do “PCC” (vide fls. 39/42).

Diante disso, em sede de verificação preliminar, os agentes policiais se dirigiram até o lava-rápido situado no endereço retro mencionado, onde se depararam com o denunciado e Alberto efetuando a lavagem de um veículo no pátio do estacionamento. Na ocasião, Alberto apresentou-se como proprietário do estabelecimento, ao passo que o denunciado informou que trabalhava para ele. Realizada busca pessoal em ambos, nada de ilícito foi encontrado.

Ocorre que, como o denunciado possuía características semelhantes às apontadas na denúncia anônima, indagaram-no se possuía algum vulgo, pelo que ele disse ser

conhecido como Cabelo.

Os policiais civis então informaram a dupla acerca do teor da denúncia anônima e indagaram sobre a existência de eventuais produtos ilícitos no estabelecimento, ao que Alberto disse que nada havia nesse sentido e que os policiais poderiam verificar.

Assim, em busca pelo local, os agentes da lei se dirigiram à parte superior do lava-rápido e, ao entrarem em um cômodo ali situado, onde havia um armário, colchão e geladeira, encontraram, no citado armário, 57 (cinquenta e sete) porções de cocaína e 03 (três) invólucros contendo maconha, além de um caderno com a contabilidade do tráfico.

Nessa oportunidade, Alberto negou que as substâncias lhe pertencessem e o denunciado, por sua vez, assumiu a propriedade de tais materiais, esclarecendo que havia ido ao local dos fatos para auxiliar Alberto na lavagem dos veículos e por isso tinha guardado as drogas naquele lugar.

Os policiais civis indagaram ao denunciado sobre a existência de mais entorpecentes em sua residência, tendo ele confirmado que mais entorpecentes poderiam ser encontrados em seu imóvel situado na Rua João Francisco Regina, n.º 300, na cidade de Osasco.

Realizada diligência ao local indicado, cuja entrada foi franqueada pelo próprio denunciado, os agentes policiais encontraram mais 429 (quatrocentos e vinte e nove) papéletes contendo cocaína, 272 (duzentas e setenta e duas) porções de maconha e 02 (dois) sacos grandes com material particulado, um deles contendo cocaína, além de 2070 eppendorfs vazios e utilizados para acondicionar cocaína.

As substâncias estavam espalhadas pela residência, sendo localizadas em um rack na sala e um armário da cozinha. No momento em que os agentes da lei desceram uma escada que dá acesso a um cômodo, constataram a presença de uma máquina seladora dos invólucros plásticos utilizados para acondicionar cocaína. Outrossim, havia dois liquidificadores, uma balança de precisão digital e mais sacos plásticos contendo substância branca aparentando ser cocaína e insumos para mistura.

Indagado sobre os fatos, o denunciado admitiu, informalmente, que as drogas lhe pertenciam e que era o responsável por embalá-las para que fossem destinadas à venda. Além disso, forneceu detalhes acerca da utilização da máquina seladora, esclarecendo que, em um período de quatro horas, ela chegava a produzir um "milheiro", ou seja, mil unidades plásticas contendo cocaína.

Por fim, disse que "Eberte", "Magrão" e "Mortão" provavelmente são apelidos do mesmo indivíduo, mas não soube dizer sua qualificação ou paradeiro, sabendo apenas que ele é responsável por fazer a retirada das drogas ilícitas já embaladas para serem comercializadas.

Em seu interrogatório extrajudicial (fls. 09/10), o denunciado disse ter se envolvido com o tráfico de drogas há oito meses, complementando que sua função consiste em guardar/ter em depósito as drogas e maquinários, além de, em algumas vezes, embalar as drogas para serem posteriormente vendidas, recebendo a quantia de R\$ 600,00 (seiscentos reais) a cada duas semanas. Enfatizou que não vende os entorpecentes, o que é feito por um comparsa não identificado que vai até sua casa para retirá-los, com a finalidade de serem vendidos posteriormente aos usuários.

Pela enorme quantidade/variedade de entorpecentes apreendidos, associada às circunstâncias de sua apreensão, incluindo a confissão informal e em sede policial, é certo que as drogas se destinavam a entrega ao consumo de terceiros.

Auto de Prisão em Flagrante às fls. 01/02.

Auto de exibição e apreensão às fls. 19/20.

Fotografias dos objetos apreendidos às fls. 29/37.

Laudos periciais às fls. 43/45, 46/49, 92/93, 94/96, 212/227 e 307/336.

Em sede de audiência de custódia (fls. 61/62 e 69/73), converteu-se a prisão em flagrante de DIEGO em prisão preventiva. Cumprimento do mandado de prisão às fls. 79/83.

Aplicando o rito comum ordinário ao feito, a denúncia foi recebida por este Juízo às fls. 116/128, no dia 21 de fevereiro de 2022, momento em que foi concedida liberdade provisória ao acusado. Cumprimento de alvará de soltura às fls. 143/148.

Posteriormente, no entanto, o E. TJSP decretou a prisão preventiva do acusado, em sede de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público (fls. 290), tendo sido determinada a expedição de mandado de prisão.

Embora não tenha sido localizado para receber a citação pessoal (fls. 242), o acusado apresentou resposta à acusação às fls. 235/237, por meio de sua Defesa constituída às fls. 114. Não foi suscitada qualquer questão preliminar e, quanto ao mérito, reservou-se, a Defesa, o direito de se manifestar em momento oportuno.

Às fls. 267 o Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de citação pessoal do réu.

Em decisão às fls. 268/273, o recebimento da denúncia foi mantido, oportunidade em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento presencial para o dia 10 de outubro de 2022, às 15h30.

Folha de antecedentes às fls. 302/303 e certidão do distribuidor criminal às fls. 337/338.

Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação e o réu, ao final, interrogado.

Em alegações finais a Acusação pediu a procedência integral.

Em alegações finais a defesa pediu o reconhecimento da confissão.

É relatório.

Fundamento e decido

O pedido é parcialmente procedente

A - Preliminarmente, destaco que a legalidade da prova será analisada juntamente com as considerações de mérito.

B - Do mérito

B.1 - Valoração probatória de autoria e materialidade

Pelo que se pode compreender da inicial são três as condutas apuradas: a) a primeira relativa ao fato de o réu agir associar-se com outra pessoa não identificada para o tráfico de drogas; b) a segunda de ter em depósito e guardar drogas para entrega a terceiros pessoas, tanto em relação às drogas encontradas no

lava-rápido quanto as drogas encontradas na residência; c) possuir maquinário e objetos destinados à preparação de drogas.

Inicialmente destaco que, com relação à droga em tese encontrada no lava-rápido, mesmo havendo autorização de Alberto para ingresso no local, segundo afirmado pelo réu em interrogatório judicial, não é possível imputar qualquer comportamento típico e ilícito de tráfico, para além de qualquer dúvida, até porque o réu afirma que era usuário e, em sua confissão, diz que “tomava conta da casa” tendo em conta dívida de droga. É crível que o réu, por possuir dívidas com o tráfico eis que também usuário, como contraprestação tomasse conta da casa na qual os policiais encontraram drogas e maquinário. Assim, não havendo certeza quanto a quantidade apreendida e, ainda, se a droga encontrada no lava-rápido, distinta da droga localizada na residência, era para consumo pessoal ou destinada a terceiros pessoas, a absolvição se impõe.

Com relação ao maquinário e drogas apreendidos no segundo local (residência), após a diligência no lava-rápido, a conclusão é outra.

Consto a que a análise das premissas fáticas expostas na inicial pelo Ministério Público para justificar a pretensão de condenação serão consideradas tanto sob a ótica do tipo penal, quanto das provas orais valoradas em contraditório judicial. Em outras palavras, buscar-se-á uma reconstrução fático-probatória que se aproxime da verdade e que vá além de qualquer dúvida razoável e possa justificar, ao final, a imposição de pena.

Encerrada a instrução do feito, depreende-se que a reconstrução fático-probatória é suficiente para a demonstração dos elementos dos tipos penais (art. 33 “caput” e art. 34 “caput” ambos da Lei 11.343/06) tanto na dimensão objetiva quanto subjetiva.

A existência material dos crimes restou demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência (fls. 13/18), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), fotografias (fls. 28/37), registro e verificação prévia da denúncia anônima (fls. 39/42), laudos de exame químico-toxicológico (fls. 92/93 e 94/96) e laudo do local do encontro dos objetos mencionados na inicial (fls. 307/304).

Quanto a imputação de autoria, tem-se que as provas valoradas em contraditório judicial permitem com a segura e devida convicção o decreto condenatório do réu em relação aos delitos dos artigos 33 e 34, eis que o réu, de fato, considerando a forma de acondicionamento, variedade e quantidade, guardava e possuía tanto entorpecentes destinado a terceiros pessoas, quanto maquinários utilizados para embalar a droga.

O réu ouvido em juízo na fase oral, negou que tivesse dito que na casa havia droga. Contudo, confirma que abriu o portão e autorizou os policiais a entrarem no local. Não conhece os nomes mencionado e não sabe quem são. Também desconhece caderno apreendido. Relatou que a casa era alugada e lá estava somente para “tomar conta do local”. Fazia um ano que trabalhava todos os dias no lava-rápido. Alberto não sabia que guardava droga no lava-rápido e por esta razão autorizou os policiais subirem. Não ganhava nada para olhar a casa. Assim fazia porque estava devendo dinheiro “para eles” por ser usuário. Por este motivo, aceitou olhar a casa. Fazia 3 meses que tomava conta da casa. A casa não era sua. No dia, ligou a máquina e mostrou como funcionava. Nunca deixou ficar muita droga no local. Tinha uns 4 kg no dia dos fatos. Não havia armário. Colocava a droga em uma sacola, na esquina, e passava alguém de moto para pegar. Era uma vez por semana. Por esta atividade não ganhava nada pois estava devendo. Os policiais pediram dinheiro, quase 50 mil reais. Não possuía esse valor. Depois que falou que não possuía dinheiro, falaram os nomes. Pegaram dinheiro do Alberto. Na casa também havia 500 reais e os policiais pegaram. Não conhece ninguém do PCC e querem vinculá-lo ao PCC porque não possuía o dinheiro

que pediram.

A confissão do réu de que guardava as drogas e estas eram destinadas a terceiras pessoas encontra suporte na prova dos autos, bem como a posse de maquinário, especialmente a máquina seladora. Logrou, neste ponto, o Ministério Público produzir provas a ponto de afastar o postulado da presunção de inocência.

O policial Marco Antônio, relatou, em resumo, em juízo que uma pessoa compareceu na delegacia e forneceu informações de que em uma casa no Jardim Helena Maria havia drogas. Passou as características da pessoa e o respectivo nome. Disse, ainda, que se a pessoa não fosse encontrada no local estaria em um lava-rápido. Com as informações, elaborou relatório e informou a autoridade. A autoridade policial, por sua vez, autorizou ir até o local. Em frente da casa mencionada na “denúncia” não logrou ver nada. Deslocou-se até o lava-rápido, não sem antes pedir apoio para que uma viatura ficasse na frente da casa. No lava-rápido avistou duas pessoas, uma das quais com as características informadas. Estas pessoas foram abordadas, dentre eles o dono do lava-rápido de nome Beto. Com eles nada foi encontrado. Foi explicada a situação para o dono do local o qual autorizou a entrada. Na parte superior seu parceiro localizou, dentro de um armário, uma determinada quantidade de cocaína. No momento o réu confirmou que a droga era dele e era para seu consumo pessoal. Aproximadamente 50 porções. O réu, após confirmar que havia droga na casa, levou os policiais. Entrou na casa e visualizou as drogas. Também havia uma máquina para embalar droga. Relata que, perguntado, o réu falou que a função dele era embalar e guardar as drogas. Disse, ainda, que alguém pegava a droga e levava para outros lugares. Relatou que o apelido do réu era “cabelo”. Recorda-se que a denúncia falava que tinha algo a ver com PCC e que a droga pertenceria a uma “pessoa acima dele” cujo apelido era “magrão” ou “mortão”. Não foi apurado quem eram essas pessoas. Não sabe dizer como era a dinâmica, pois somente “fizeram o básico”. “Somente acharam a droga” na casa e no lava-rápido. Não houve investigação. O réu falou que armazenava e embalava. Ele mostrou a máquina. Disse que fazia “um milheiro a casa 4 horas”. Não disse quanto ganhava e também quem buscava a droga. Disse apenas que alguém buscava e que não vendia droga. No lava rápido encontraram a droga e o réu disse que era dele. Não havia dinheiro. Havia uma balança, liquidificador, eppendorfs vazios e saquinhos. Também havia “maconha” e “cocaína”. O dono do lava-rápido (Beto) sempre negou. Quando chegaram os dois estavam lavando carro. Relatou que não sabe dizer há quanto tempo o réu estava na atividade, talvez pouco mais de um mês. O réu estava ajudando o colega no lava-rápido para ganhar um dinheiro. Havia um caderno que seu parceiro encontrou. Não sabe quem é Ebert.

No mesmo sentido a versão da testemunha Danton. Acrescentou que as características da “denúncia anônima” era uma pessoa branca, cabeluda, barba, de apelido cabelo. Confirmou a apreensão de um caderno mas não sabe o que havia em seu conteúdo. Confirmou a localização da máquina e que o réu, na oportunidade, disse que a função era guardar a droga e “envelopar”. Não descobriram quem era “magrão” ou “mortão”.

Pois bem. Anote-se que, quanto ao motivo dos policiais se dirigirem ao lava-rápido e depois na residência foi uma “denúncia anônima”. No caso em concreto, verifica-se que a referida “denúncia anônima” foi precedida de verificação prévia, relatório e autorização da autoridade policial para as investigações (fls. 39/42). Assim, tem-se dos autos alguma concretude que dá suporte a atividade de polícia judiciária.

As testemunhas policiais não discrepam em suas versões, possuem linearidade e, também, reciprocamente são coerentes e, acima de tudo, estão consentâneas com as demais provas produzidas, especialmente com as provas materiais e a própria confissão do réu.

Na fase de valoração, não há por que se duvidar da versão dos policiais. A qualidade de policial, por si só, não infirma a prova ou a torna mais importante. Não é por que a pessoa é policial e que participou da ocorrência que sua versão

ganha mais ou menos credibilidade. A credibilidade da versão apresentada deve ser valorada de forma racional de maneira a verificar se ela possui coerência interna e, ainda, se possui coerência externa quando corroborada com as demais provas apresentadas.

Nesse sentido: (...) 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. (...) (STJ – 5ª Turma - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.936.393 - RJ – Rel. Min. RIBEIRO DANTAS – j. 25.10.2022).

É certo o réu guardava drogas na residência, fato esse assumido e demonstrado pelas provas, e que o entorpecente era destinado ao consumo de terceiro. Também é certo, diante da confissão, da prova material e do relato dos policiais, que o réu possuía uma máquina para embalar a droga, além de balança. Portanto, as premissas fáticas do Ministério Público de que o réu guardava drogas, para entrega ao consumo de terceiros e possuía maquinário e objetos destinados à preparação de droga restaram comprovadas nos autos.

As provas demonstram, para além de qualquer dúvida, de fato, a conduta de guardar entorpecente, sem autorização legal e regulamentar, de forma consciente, e que as drogas seriam para consumo de terceiros (o réu falou que deixava uma sacola para terceiro recolher), tendo em vista a forma como acondicionadas (porções individuais), a quantidade, o maquinário para embalagem e insumos e as condições nas quais se desenvolveu a ação.

Por outro lado, quanto ao crime de associação para o tráfico, a absolvição se impõe.

Em primeiro lugar, dos autos tem-se, como é comum em fatos da mesma espécie, que não houve qualquer investigação a desvendar um concerto delito. A prova se esgota no auto de prisão em flagrante. Não há incremento probatório. A autoridade policial não levou a cabo investigação na tentativa de saber quem eram as pessoas envolvidas ou mesmo que a atividade de guardar drogas teria relação com alguma organização criminosa.

A autoridade policial limitou-se a expedir ordem de serviço (fls. 97/98) para verificação de quem seria “Ebert”. Na sequência a investigação respondeu dizendo que “não localizou” (fls. 99).

Em mais, de fato, a “denúncia anônima”, quando verificada e de alguma forma materializada, é elemento para iniciar-se as diligências, como, no caso, ir ao lava-rápido e na residência. Agora, não se poder ter como prova o conteúdo da “denúncia” que menciona eventual “relação com o PCC” e tomar-se essa informação como certa e absoluta. Deve a autoridade investigar. Aliás, esta é a função constitucional da polícia judiciária e para qual está investida.

Como se não bastasse, as testemunhas afirmam que a droga pertenceria a uma pessoa acima do réu cujo apelido era “magrão” ou “mortão”, contudo, não foi apurado quem seriam essas pessoas. Também não foi investigado. Também não souberam explicar a dinâmica dos fatos. Nesse sentido, a testemunha Marco Antônio, o que comprova que a produção probatória se esgota no flagrante, disse que somente “fizeram o básico” e que “somente acharam a droga” na casa e no lava-rápido. “Não houve investigação”.

A pergunta que fica é: de posse das informações constantes da denúncia anônima, por qual motivo não fora, ao menos, realizada uma “campana” (técnica de investigação tão largamente utilizada na comarca de Osasco) para verificar eventual reiteração ou mesmo entrega isolada de drogas, como exige o tipo do artigo 35?

O crime do art. 35 da Lei de Drogas antecipa a tutela penal no sentido de se punir qualquer concerto delitivo antes que o crime fim seja levado a efeito. Por ser crime de consumação antecipada, é de rigor que haja investigação que demonstre o concerto delitivo. Sem outras investigações, não há como afirmar, para além de qualquer dúvida, que juntamente com pessoa não identificada, o réu teria estabelecido vínculos de estabilidade e permanência.

A afirmação do réu realizada em confissão judicial de que deixava uma sacola para outra pessoa pegar é suficiente para demonstração do tráfico (destinação da droga), até porque não se trata de prova isolada, tendo em conta as demais provas, contudo, a mesma afirmação não pode ser considerada como prova para tipificação do crime de associação, eis que, para este delito, resta isolada nos autos e, por si só, não demonstra um concerto delitivo prévio, ainda que somente para um ato não reiterado de tráfico, como exige o art. 35.

Portanto, não restou demonstrado, de forma segura, com provas além da confissão do réu, o animus associativo. Nesse sentido sustenta Vicente Greco Filho: "Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris*, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a co-autoria". (in, Tóxicos. 13 ed. Editora Saraiva, 2009, p. 184/185).

Também: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. MINORANTE. REGIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. (STJ - AgRg no HC 661393 / SP - 6ª T - Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ - j. 22/06/2021 - Dje 28/06/2021).

Assim, todos os elementos do tipo penal do art. 33, "caput" e 34 "caput" da Lei n. 11.343/06 restaram demonstrados, inclusive a vontade livre e consciente de guardar a droga que seria destinada ao tráfico, bem como maquinário utilizado na preparação. Relativamente a estes delitos, não há qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Por outro lado, não há provas seguras do crime do art. 35, "caput" da Lei n. 11.343/06.

Com relação ao redutor, embora o réu seja primário, não possua antecedentes e não haja elementos seguros de que integre organização criminosa, dedica-se à atividade criminosa.

Malgrado o réu tenha negado o vínculo associativo a qualquer pessoa, o que basta para afastar a tipicidade do art. 35, confessou que, tendo em conta dívidas, aceitou tomar conta do local e já o fazia por três meses, até ser preso. Inclusive mostrou aos agentes policiais como a máquina seladora funcionava. Também o próprio réu afirmou que nunca deixou ficar muita droga no local. Nesse sentido, essa configuração fática é suficiente para afastar-se o redutor do §4º.

Por fim, quanto ao concurso de crime é necessário nova adequação típica.

Relativamente as condutas de guardar drogas e possuir máquina destinada a preparação, descritas na inicial, verifica-se que o Ministério Público, subjacentemente, está imputando duas relações de posse no mesmo contexto. Vale

dizer, o réu, ao aceitar tomar conta da casa, logrou o domínio fático dos objetos (drogas e maquinário) e este domínio possibilitou o respectivo controle representado pela fruição (drogas entregues a terceiros e máquinas utilizadas na preparação). Assim, verifica-se que o réu, mediante uma só ação fática de posse (subjacente aos verbos guardar e possuir) praticou dois delitos, o que permite o reconhecimento do concurso formal de crimes. Quanto ao desígnio, impõe-se anotar que tanto a guarda da droga quanto a posse do maquinário visava a uma única finalidade, o tráfico de drogas.

C - Da dosimetria da pena

Reconhecida a responsabilidade penal, observando o roteiro legal-dogmático do art. 68 do Código Penal, passo a aplicar a pena, anotando que ao final será reconhecido o concurso formal heterogêneo.

C.1 - Pelo crime do art. 33.

Na primeira fase da dosimetria da pena, não obstante o réu seja primário e não ostente antecedentes, considerando o art. 42 da Lei 11.343/2006 e o art. 59 do Código Penal, com preponderância daquele, em especial a quantidade, as espécies de drogas apreendidas e os utensílios fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, aumentando-a em 1/6, o que perfaz 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias multa (STF - HC nº 91.487/R0. 1ª Turma. Rel. Mm. Carmen Lúcia.j 11/09/2007, AgRec no HC - n. 181.632-PR - Rel. Min. Roberto Barroso e STJ - AgRg no HC 590.270/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 02/09/2020).

Na segunda fase, diante da confissão, e de sua valoração como prova, retomo a pena a 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento 500 dias multa.

Na terceira fase, pela fundamentação acima, deixo de aplicar o redutor de pena previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Cada dia-multa será fixado no mínimo, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

C.2 - Pelo crime do art. 34.

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias multa.

Na segunda fase, mesmo diante da confissão observo que a pena fora fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Cada dia-multa será fixado no mínimo, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Diante do reconhecimento do concurso formal heterogêneo, uma vez que o réu mediante uma ação praticou dois crimes diversos, considero a pena do crime mais grave. Contudo, uma observação: em relação a pena privativa, o acréscimo será em relação ao crime do art. 33. Em relação à pena pecuniária o aumento é com base na pena pecuniária do preceito penal do art. 34. Assim, com fundamento no art. 70 "caput" aumento a pena em 1/6 o que perfaz 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 1400 dias multa.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento de pena (art. 33, §2º, "b",

CP), diante da quantidade de pena, pelo fato do réu ser primário, ter confessado o crime e, ainda, tendo em conta que a disposição do art. 2º, §1º da Lei 8.072/90 não é de aplicação automática. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. 2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido. (ARE 1052700 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 02/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018

D- Do dispositivo:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da presente ação penal e:

ABSOLVO o acusado DIEGO TOTH EVANGELISTA da acusação de ter infringido o artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal.

CONDENO DIEGO TOTH EVANGELISTA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 1400 dias multa, no valor mínimo, com atualização desde o trânsito em julgado, por infração ao artigo 33, caput e 34 caput, da Lei n. 11.343/06, ambos na forma do art. 70 "caput" do Código Penal.

E - Demais deliberações

Considerando o regime de pena inicialmente fixado, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade diante da incompatibilidade do regime intermediário com a custódia cautelar. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (STF - HC. 186.648 - Min. Cármen Lúcia - j. 08.06.2020). Também: HABEAS CORPUS n. 204.618 - SC - Min. Alexandre de Moraes - j. 19.07.2021). também: HC n. 213.750, Rel. Min. Ministro Edson Fachin, DJe 05.04.2022. Ainda, anoto a atual recomendação do CNJ a qual determina a expedição de guia de recolhimento sem a necessidade de expedição de mandado de prisão. Assim, por mais esse argumento, a fixação de regime semiaberto se mostra incompatível com custódia cautelar (Resolução 474 do CNJ e Comunicado CG nº 628/2022 (CPA 2021/104300).

Expeça-se alvará de soltura.

Transitada em julgado a presente sentença condenatória ou eventual acórdão condenatório:

Autorizo a destruição dos entorpecentes. Oficie-se.

Determino a destruição/leilão dos objetos apreendidos. Oficie-se.

Tendo em vista o quanto relatado pelo réu no sentido de não ter sido apresentada a mesma quantia de droga apreendida e, ainda, de ter havido solicitação de vantagem indevida, e, outrossim, tendo em conta o não cumprimento da Portaria n. 2º, de janeiro de 2022, da Delegacia Geral de Polícia de São Paulo, nos termos do art. 40 do CPP, oficie-se ao GECEP - MP (Grupo Especial de Controle Externo da Atividade Policial), bem como à Corregedoria da Polícia Civil para as providências necessárias.

No mais, façam-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive para o Instituto de Identificação Criminal e para o Tribunal Regional Eleitoral competente, para fins do art. 15, inciso III, da CF.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Osasco, 29 de novembro de 2022.